

1501638-10.2021.8.26.0082

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS
Comarca: Boituva
Foro: Foro de Boituva
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... consideradas de uso próprio.

Neste sentido:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DE TRÁFICO PARA O CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. APELO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161,18550-073 - Boituva - SP

Telefone: (015) 3416-6252 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1501638-10.2021.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501638-10.2021.8.26.0082

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SILVANA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

SILVANA DOS SANTOS, já qualificada nos autos, foi denunciada às fls. 70/72 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia 05 de dezembro de 2021, por volta das 03h00min, na Rua Oito, nº 24, George Oetterer, no município de Iperó, Comarca de Boituva, adquiriu e tinha em depósito, para fins de tráfico, 4,3g (quatro gramas e trinta centigramas) líquidos de cocaína, acondicionados em 16 (dezesseis) porções e 0,31g (trinta e um centigramas) líquidos de crack, acondicionados em 03 (três) porções, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto. Prisão em Flagrante em 05 de dezembro de 2021 (fl. 01). Concessão de liberdade provisória mediante cautelares às fls. 45/46.

Decisão às fls. 74 de notificação para apresentação de defesa. Ré notificada em 28 de janeiro de 2022 (fls. 81). Apresentação de Defesa prévia em 06 de março de 2022 (fls. 85/112), a qual pugna pela preliminarmente pela inépcia da denúncia, a nulidade da investigação realizada pela guarda municipal, alegada ilicitude da prova obtida na residência da ré.

Decisão pelo recebimento da denúncia às fls. 113/114, com designação da audiência de instrução e julgamento.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi devidamente interrogado, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com aplicação da pena em seu mínimo legal e fixação de regime inicial aberto.

Já a Defesa postulou, preliminarmente, pela nulidade da investigação, pela ilicitude da prova obtida em busca e apreensão e, no mérito, a desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 e, de forma subsidiária, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Com relação às preliminares arguidas, nenhuma merece acolhimento.

Não há que se falar em inépcia da denúncia. O Ministério Público detalhou a conduta e elementos constantes nos autos e seguiu estritamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

No tocante às alegações de nulidade de investigação realizada pela Guarda Municipal, estas, mais uma vez, não merecem guarida. Lembra-se que foi efetuada prisão em flagrante da ré, e não investigação, como faz crer. E, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender em flagrante. E, se a qualquer pessoa é conferido o poder da prisão em flagrante, inquestionável que à guarda municipal, como representante do povo dentro daquele Município, não caberia ação diferente.

Na mesma esteira seguem as alegações de prova ilícita obtida em busca e apreensão na residência da ré, trazendo o direito à inviolabilidade de domicílio. Novamente não comportam provimento.

A uma, pois, conforme se constatou não se tratava de domicílio, e sim de estabelecimento comercial, denominado "Copão Point 20", que, pelo trazido pelos guardas municipais e confirmado pela ré em seu interrogatório, estava aberto no horário dos fatos.

A duas, porque os depoimentos dos guardas municipais foram consistentes e contundentes em afirmar que a própria ré confessou a prática do crime e apontou onde guardaria os demais entorpecentes. E, vale lembrar, a palavra dos guardas possui fé pública e a ré não trouxe nenhuma prova capaz de se tirar tal credibilidade, sendo suas alegações em Delegacia frágeis e facilmente refutáveis.

A três, pois o artigo 240, § 2º do Código de Processo Penal confere a possibilidade de busca e apreensão e, não obstante a argumentação trazida pela ré, no caso em tela, havia fundada suspeita dela possuir objetos ilícitos dentro de seu estabelecimento depois da indicação feita por terceiro usuário.

Vale lembrar que o artigo 5º da Constituição Federal ao estabelecer a inviolabilidade do domicílio excepciona alguns casos, dentre eles os de flagrante delito e, saliente-se, o entendimento majoritário das Cortes trazem o tráfico como crime permanente e, conseqüentemente, passível de busca e apreensão sem mandado, vez que se enquadraria como flagrante.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. BUSCA PESSOAL EFETUADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em

10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexistente óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria transportando droga em seu veículo. No caso, ao receberem a notícia de que o paciente fazia o transporte de drogas em seu veículo, os guardas municipais primeiro identificaram o referido automóvel e fizeram sinal de parada, o réu se negou a parar e tentou fugir, gerando a suspeita da prática de crime, o que justificou a abordagem. Na sequência, ao finalmente parar o carro, o réu saiu dizendo “ladrão”, “perdi”. Além disso, o veículo possuía cheiro de entorpecente. Tudo isso, motivou a busca veicular, a apreensão do entorpecente e a prisão em flagrante. 4. Agravo Regimental improvido. (AgRg no HC 635.303/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). No tocante ao mérito da ação penal, esta é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecente está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01/02), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 16), pela fotografia (fl. 26), pelo Laudo Pericial de Constatação (fls. 27/31), pelo Relatório Final (fls. 65/66) e pelos depoimentos colhidos.

O laudo pericial (fls. 27/31) concluiu que os materiais examinados se tratavam de cocaína, substância que está na lista dos entorpecentes e psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Válido o laudo, configurada a materialidade do delito.

Não ocorre de modo diverso em relação à autoria.

Em depoimento na Delegacia, o Guarda Civil César de Souza declarou que estava em patrulhamento pelo bairro Campos Vileta, no município de Iperó, oportunidade em que avistou um indivíduo fazendo uso aparentemente de cocaína em frente a um bar. Informa que, quando abordado, foi questionado sobre onde havia adquirido a droga, tendo ele informado que havia comprado ali mesmo, no bar da Silvana. Durante a abordagem, Silvana dos Santos, dona do estabelecimento, saiu do bar e perguntou o que estava acontecendo, e ao ser inquirida acerca da venda de entorpecentes, teria admitido que estava traficando por necessidade, pois é sozinha e tem crianças para sustentar, mostrando, em seguida, uma gaveta do balcão, onde estavam guardadas dezesseis (16) porções de substância semelhante a cocaína e três (3) porções de substância semelhante a crack, além de R\$ 1.628,65 (mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos) em dinheiro. Finaliza informando que o usuário abordado no local foi dispensado, não tendo havido apreensão de qualquer droga com ele.

Em juízo, confirmou suas declarações, acrescentando que não conhecia o bar como ponto de venda de droga, e tampouco conhecia a ré, não ocorrendo nova abordagem após os fatos. Que ela declarou que recebeu as drogas de uma mulher que havia conhecido na rede social. Contou que os invólucros das drogas apreendidas na gaveta do estabelecimento eram semelhantes ao do indivíduo que estava consumindo a droga em seu exterior. Que o indivíduo foi descrito como pardo, 1,70m, magro, sem sinais aparentes ou características marcantes em seu rosto. Que tal indivíduo inicialmente abordado não foi conduzido à Delegacia porque o resto de drogas de consumo que ele detinha foram descartadas ali mesmo.

Ainda em solo policial, o Guarda Civil Municipal Marialdo Souza Pinto conta que se encontrava em serviço com o GCM Souza, em patrulhamento de rotina, tendo avistado um indivíduo usando aparentemente cocaína defronte a um bar, abordando-o, ocasião em que o indivíduo afirmou ter comprado o entorpecente no bar e, enquanto era questionado, Silvana, proprietária do referido bar, saiu à rua e perguntou o que estava ocorrendo. Ao ser questionada sobre a venda de entorpecentes, confessou que realmente estava vendendo drogas no local, pois seria sozinha e com filhos para

criar, tendo ela mostrado o local onde as drogas estavam guardadas, qual seja, uma gaveta do balcão. Que ali havia dezesseis microtubos contendo aparentemente cocaína e três microtubos contendo aparentemente crack. Na gaveta também havia R\$ 1.628,65 (mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos) em dinheiro. Contou que ela teria lhe relatado ainda que as drogas seriam fornecidas por uma moça branca, de cabelo liso, que conheceu pelo Facebook, não tendo fornecido maiores detalhes sobre tal pessoa. Finaliza informando que o usuário inicialmente abordado foi dispensado e não foi qualificado, não sendo apreendida nenhuma droga com ele.

Em audiência, confirmou suas declarações e explicou que não conduziram o indivíduo à delegacia porque a ré confessara a conduta e porque o resto de drogas que ele tinha fora jogado fora. Que ela esclareceu que havia obtido as drogas de uma moça de Sorocaba, que conheceu nas redes sociais e que o dinheiro apreendido era proveniente da venda. Contou que o invólucro encontrado com o indivíduo era semelhante aos invólucros apreendidos no estabelecimento da ré. Que não conhecia o indivíduo e que o restante da droga que havia sobrado de seu uso foi descartado no próprio local. Que o indivíduo teria indicado o local da compra como "o local em que estava em frente", e que ele estava em frente ao bar da ré.

Durante interrogatório policial, a ré narra que é proprietária do bar denominado "Copão Point 20", sendo que na data dos fatos, por volta das 02h30min, estava se preparando para fechar o estabelecimento quando a Guarda Municipal de Iperó passou e abordou uns rapazes do lado de fora do bar. Afirma que quando já estava fechando o portão, um dos guardas colocou o pé para impedir que o portão fosse fechado e disse que iria entrar para olhar o estabelecimento, o que não foi autorizado por ela, porém o GCM disse: "não tem que autorizar, a gente vai entrar porque o moleque está com o nariz todo branco e usou aqui". Afirma ter dito ao guarda que os indivíduos abordados estavam na rua, onde a interroganda nada podia fazer e só poderia tomar alguma atitude se estivessem consumindo entorpecentes do portão para dentro, o que não ocorreu. Relata que um dos GCMs entrou no bar e, revirando tudo, teria encontrado sobre um armário uma bolsa que lhe pertencia, a qual continha uns nove (9) "pinos" de cocaína, que eram de seu uso antes de descobrir que está grávida. Afirma que após encontrar a droga o guarda chamou seu companheiro e pegaram o dinheiro que estava no caixa, que é fruto das vendas do bar, e lhe deram voz de prisão, tendo esta argumentado que era apenas usuária, mas eles responderam que com aquela quantidade de dinheiro caracterizava tráfico. Afirma que perguntaram se ela iria por bem ou à força, a menos que lhes desse alguma informação grande, embarcando na viatura, e, devido à velocidade que empreenderam, teria passado mal, sendo conduzida ao PA. Finaliza negando ser traficante, nunca comercializando drogas, tendo dito aos guardas que ganhou a droga ora apreendida de uma moça de Sorocaba, a qual conheceu pelo Facebook e em cuja companhia foi a uma "rave" e, ao tomar ciência das drogas apreendidas, alegou que somente havia nove microtubos de cocaína em seu poder anteriormente.

Em juízo, negou que tivesse vendido os entorpecentes e que os guardas em princípio abordaram uns moleques que se encontravam na frente do bar. Que depois entraram no bar e o dinheiro estava no caixa, as drogas estavam em uma bolsa, que pertencia a uma amiga sua e estava em cima de um armário nos fundos. Que nunca foi presa.

Pois bem.

Em que pese as alegações de defesa e a versão da ré, as provas conduzem à conclusão do crime de tráfico.

A versão da ré restou isolada e contraposta pelas demais condições de fato, quais sejam, ela se encontrava com dinheiro, em quantidade relevante e, muito embora alegue ser fruto de seu comércio, deixou de comprovar sua origem lícita; o indivíduo abordado afirmou ter comprado no estabelecimento, onde não há notícias de que havia outras pessoas, tanto que a ré dizia que já ia fechá-lo.

Além disso, a alegação da ré de que a droga estava em uma bolsa, e pertencia a uma amiga, não fosse destituída de qualquer prova, é totalmente inverossímil.

Verossímil, ao contrário, é a concatenação dos fatos declarada pelos Guardas, de que abordaram uma pessoa, que indicou o bar e que a ré, questionada, confessou a traficância e mostrou os demais entorpecentes.

Salta aos olhos, ainda, que a versão da ré dada em juízo é completamente contraditória com a dada na unidade policial.

Como apontado pelo Ministério Público, os guardas foram inclusive uníssonos nos detalhes que a ré deu sobre como adquiriu as drogas.

Nota-se, também, que o local não era visado dos Guardas e, ademais, eles explicaram a razão pela qual não conduziram o terceiro usuário à delegacia.

Por fim, quanto ao requerimento de desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, este não merece guarida.

Primeiro que a quantidade de drogas encontradas no estabelecimento da ré não é condizente com o uso próprio.

Embora a legislação não preveja uma quantidade para que o indivíduo seja enquadrado ou não como usuário, fato é que se deve usar o bom senso para análise de tal elemento. E, me parece desproporcional considerar-se que 16 porções de cocaína e 03 de crack possam ser consideradas de uso próprio.

Neste sentido:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DE TRÁFICO PARA O CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. APELO PROVIDO. 1.

"(...) Mostrando-se incompatível com o mero consumo próprio a quantidade e variedade de droga apreendida, não há como ser feita a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06." (TJMG. Ap Crim.

1.0024.18.044657-7/001, Rel.: Fernando Caldeira Brant, 4ª C. CRIM., julg.:

22/01/2020, publ.: 29/01/2020) 2. Se a quantidade de droga apreendida revela-se

incompatível com a condição de usuário sustentada pelo agente, impositiva a

condenação pelo tráfico. 3. Apelo provido. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº

00069264320188150011, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOAS DE BRITO

PEREIRA FILHO , j. em 02-06-2020) (TJ-PB - APL: 00069264320188150011 PB 0006926-

43.2018.815.0011, Relator: DES. JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO, Data de Julgamento:

02/06/2020, Câmara Especializada Criminal)

Ademais, o terceiro consumidor abordado no exterior do bar apontou o local de compra, e as testemunhas foram categóricas em informar a similitude entre os invólucros encontrados com a ré, e o apreendido com o usuário.

Tais fatos apontam diretamente para a traficância da ré, o que justifica sua condenação.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Fixo a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras.

Na segunda fase, não há causas atenuantes ou majorantes para alteração da pena.

Na terceira fase, por ser primária reconhece-se o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da lei 11.343/2006). Destarte, cabível a minorante. Diminuindo a pena no máximo, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

No que atine ao regime inicial de pena, o STF (HC 118.533) e o STJ (por meio do Tema 600 em sede de recurso repetitivos) vêm orientando que o chamado tráfico privilegiado não é crime hediondo.

Ao lado disso, considerando que a ré é primária, apesar da perniciosidade desse crime, fixo-lhe o regime aberto de prisão.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porque não é uma infração penal que pode ser qualificada como de pequeno desvalor social.

A capacidade econômica da ré autoriza que o valor do dia-multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar SILVANA DOS SANTOS a cumprir pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, porque incursa no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista que a ré respondeu solta pelo processo, poderá apelar em liberdade. Decreto o perdimento do valor depositado nos autos (R\$ 1628,65 - fls. 64) em favor da União, para reversão ao Funad.

Autorizo a incineração dos entorpecentes remanescentes.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, proceda-se ao necessário e após arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA